

主要是针对信用卡套现行为作出的特别规定，不涉及“养卡”行为。

3. 从社会危害性看，信用卡套现行为将金融机构资金置于高度风险之中，给发卡银行带来信贷风险。“养卡”行为中，持卡人的信用卡本身已经透支且无力归还，行为人的代还代刷行为，没有给银行造成信贷风险，行为人为持卡人归还本期账单，通过虚构交易方式产生新账单的行为，变相延长了还款期限，缓解了持卡人资金压力，对于确保银行顺利收款起到一定的帮助作用，其社会危害性明显小于信用卡套现。

4. 从罪责刑相适应角度看，“养卡”行为不应适用《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定的定罪处罚。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，使用POS机套现，数额在100万元以上，或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失10万元以上的，构成非法经营“情节严重”；达到上述标准5倍以上的，构成非法经营“情节特别严重”。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》规定，非法经营数额在500万元以上的，或者违法所得数额在10万元以上的，应当认定为“情节严重”；达到上述标准5倍以上的，构成非法经营“情节特别严重”。根据上述规定可以明显看出，对于信用卡套现行为的打击力度更大，入罪及上档标准均明显少于其他非法资金支付结算行为，对于信用卡套现行为的理解应做严格现缩，不应扩大

其外延。因信用卡套现与“养卡”行为的社会危害性明显不同，从罪责刑相适应角度出发，对于“养卡”行为也应分别适用不同的定罪量刑标准，

综上，本案被告人王某等人违反国家规定，使用POS机从事信用卡代还款业务，非法经营数额达3亿余元，情节特别严重，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》的规定，构成非法经营罪，依法定罪量刑。

编写人：江苏省沭阳县人民法院 周妮 邵嘉 刘玲玲

非法经营电子烟类案件中的电子烟认定及案件的定性

—— 余某1等非法经营案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江苏省南京市鼓楼区人民法院(2023)苏0106刑初404号刑事判决书

2. 案由：非法经营罪

【基本案情】

1. 2022年10月起，被告人余某1在未取得烟草专卖许可证的情况下，从被告人黄某1等上家处购进电子烟制品，再加价销售给被告人方某1、方某2，销售金额共计人民币126502元。其间，余某1雇佣、安排被告人余某2对接、监督“上家”生产、打包发货等工作。

另外，2023年2月余某1与客户商定代加工一批电子烟制品并销售，民警在余某1的仓库中查扣成品电子烟524只(价值13886元)。民警在上述仓库同时查扣烟杆、烟芯、烟嘴、内置充电线、烟油、包装盒、金属电子杆等生产配件若干；在余某1的住所及办公地点查扣草本烟杆、草本烟芯、空烟弹、烟油等。上述电子烟半成品及配件价值47519.35元。2023年2月21日，公安机关另在余某1的住处及办公地点查扣电子烟制品426只(价值7668元)。

2. 被告人黄某1在未取得烟草专卖许可证的情况下，生产电子烟销售给余某1等人。被告人黄某2在明知黄某1在未取得烟草专卖许可证的情况下，生产电子烟并对外销售，仍向其提供电子烟配件。2022年10月13日至2023年2月16日，黄某1、黄某2生产、销售电子烟共计203971元。

3. 2022年10月起,被告人方某1在未取得烟草专卖许可证的情况下,从余某1等商家处购进电子烟制品,再加价销售给客户。截至2023年2月22日,方某1销售电子烟制品金额共计232575元、63190元。

4. 2022年10月起,被告人方某2在未取得烟草专卖许可证的情况下,从余某1等商家处购进电子烟制品,再加价销售给客户。截至2023年2月22日,方某2销售电子烟制品金额共计59530元。

2023年2月21日,被告人余某1、黄某2、黄某1、方某1、方某2被公安机关抓获归案。次日,被告人余某2经民警电话通知后主动投案。上述被告人到案后均如实供述了上述主要事实。案发后,被告人余某1、黄某2、黄某1、方某1、方某2分别退出违法所得16000元、6000元、8000元、30000元、10000元。

【案件焦点】

1. 如何认定涉案产品属于“电子烟”;2. 司法解释虽未直接规定将电子烟纳入非法经营罪的对象范围,2022年10月后行为人非法经营电子烟的能否构成非法经营罪。

【法院裁判要旨】

江苏省南京市鼓楼区人民法院经审理认为:被告人余某1、余某2、黄某2、黄某1、方某1、方某2违反国家规定,未经许可经营电子烟制品,扰乱市场秩序,情节严重,其行为均构成非法经营罪,其中被告人余某1系与余某2共同犯罪,被告人黄某2系与黄某1共同犯罪。被告人余某2在共同犯罪中起次要、辅助作用,系从犯,应从轻处罚。被告人余某2主动投案,与被告人余某1、黄某2、黄某1、方某1、方某2到案后均能如实供述自己的犯罪事实,分别构成自首、坦白,并自愿认罪认罚,依法均可从轻、从宽处理。被告人余某1、黄某2、黄某1、方某1、方某2退出违法所得,可酌情从轻处罚。据此,依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项,第二十五条第一款,第二十七条,第六十七条第一款、第三款,第七十二条第一款、第三款,第七十

三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一、被告人余某1犯非法经营罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币6万元，被告人余某2犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币2万元，被告人黄某2犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币3万元，被告人黄某1犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币4万元，被告人方某1犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币15万元，被告人方某2犯非法经营罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币5万元；

二、在案的电子烟成品、半成品、配件及用于生产电子烟及配件的工具予以没收；违法所得予以没收，上缴国库。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

本案的第一个争议焦点是被告人余某1等人经营的物品是否属于电子烟。根据《电子烟管理办法》第三条的规定，电子烟包括烟弹、烟具以及烟弹与烟具组合销售的产品等。该办法同时规定，设立电子烟生产企业(含产品生产、代加工、品牌持有企业等)、雾化物生产企业和电子烟用烟碱生产企业等，需经国务院烟草专卖行政主管部门批准，取得烟草专卖生产企业许可证，并经市场监管管理部门核准登记。上述规定简要规定了电子烟的含义，同时明确将电子烟的生产纳入行政审批范围。《电子烟》(GB 41700-2022)明确，电子烟是“用于产生气溶胶供人抽吸等的电子传送系统”；电子烟烟液为“液体形态的雾化物”“雾化物应含有烟碱”；电子烟释放物为“抽吸电子烟产生的气溶胶”。依据上述标准，电子烟应为含有烟碱的产生气溶胶的电子传送系统。其中并不包括加热不燃烧型的固态电子烟。实践中，加热卷烟为外观与卷烟相似，内部包裹丝、末、粒状等物品且通过加热释放出含烟碱(尼古丁)等烟气的产品，该回复实际将固态电子烟纳入了加热卷烟的概念范畴，认为其不再属于电子烟。

依据上述相关规定，判定涉案产品是否为电子烟，主要应考虑以下几点：

